刑法主題整理：阻卻違法事由

> 整理範圍：108-114年司律一試刑法考題
> 涵蓋主題：正當防衛、緊急避難、依法令行為、義務衝突、被害人承諾、誤想防衛
> 題數：12 題

壹、正當防衛（刑法§23）

一、正當防衛要件（112年第6題）

關於正當防衛之敘述，下列何者錯誤？

(A) 在業務上有特別義務者，不得為自己之權利主張正當防衛
(B) 在判斷正當防衛的要件時，原則上毋須考量利益衡量的問題
(C) 對於無責任能力人之不法侵害，仍然可以實施正當防衛
(D) 行為人主觀上必須具備防衛意思，才可以主張正當防衛

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤（本題答案）	業務上有特別義務者（如警察、消防員），學說上認為其正當防衛僅受「社會倫理限制」，在防衛手段上應有所節制，但**並非完全不得主張正當防衛**。此選項將限制說成「不得主張」，過於絕對而錯誤。
(B)	☑ 正確	正當防衛與緊急避難不同。緊急避難涉及合法利益之犧牲，需利益衡量；正當防衛是對不法侵害之回應，**原則上不要求利益衡量**（「正不必向不正讓步」）。
(C)	☑ 正確	正當防衛的要件是「現在不法之侵害」，侵害者的行為只要客觀上具有不法性即可，**不以侵害者具備責任能力為必要**。故對精神病人、幼童等無責任能力人之客觀不法侵害，仍得主張正當防衛。
(D)	☑ 正確	通說認為正當防衛需具備主觀之**防衛意思**，即行為人認識到現在不法侵害存在，並基於防衛之意思而為反擊行為。

> [!NOTE]
> **重點整理**
> 正當防衛五要件：(1) 現在不法之侵害、(2) 對自己或他人權利之防衛、(3) 防衛行為之必要性、(4) 防衛手段之相當性、(5) 防衛意思。正當防衛原則上**不需利益衡量**，僅在社會倫理限制下有所節制（如業務上特別義務者、親屬間、可歸責之挑唆防衛等）。

二、互毆與正當防衛（111年第5題）

甲乙相約在廢棄倉庫裡談判，當天，習武多年的乙一人前往，但甲卻帶了幾名手持棍棒及刀具的同夥赴約。甲一到場就叫同夥把倉庫鐵門關上，讓乙無法離開，也讓聲援乙的兄弟無法進來。結果雙方一言不合，大打出手，乙幾個回合就輕鬆解決甲及甲的同夥，造成甲身受重傷，同夥丙丁戊三人輕傷。下列敘述何者正確？

(A) 甲連同同夥與乙互毆的行為，不成立刑法第283條之聚眾鬥毆罪
(B) 甲叫同夥把鐵門關上，讓乙無法離開的行為，不成立刑法第302條私行拘禁罪
(C) 乙將丙丁戊打成輕傷的行為，僅得依緊急避難而阻卻傷害罪之違法性
(D) 乙將甲打成重傷的行為，可主張得被害人承諾而阻卻重傷罪之違法性

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確（本題答案）	依111年修正後之刑法第283條聚眾鬥毆罪，須「在公共場所或公眾得出入之場所」聚集三人以上施強暴脅迫。**廢棄倉庫非公共場所或公眾得出入之場所**，且甲叫同夥關上鐵門，僅限於特定人，不符合本罪要件。
(B)	✗ 錯誤	甲叫同夥把鐵門關上，**使乙無法離開**，已構成剝奪乙之行動自由，成立刑法第302條私行拘禁罪。
(C)	✗ 錯誤	乙遭甲連同多名同夥攻擊，面對現在不法侵害，乙將丙丁戊打傷之行為應得主張**正當防衛**（§23）阻卻違法，而非僅能主張緊急避難（§24）。正當防衛不要求利益衡量，較有利於防衛人。
(D)	✗ 錯誤	互毆雙方雖有互相攻擊之事實，但**不能認定雙方已互為承諾對方之重傷害**。被害人承諾不適用於重大身體法益之侵害（如重傷），且互毆不當然等於被害人承諾。

[!NOTE]
重點整理

1. **互毆與正當防衛**：實務見解認為互毆雙方均有攻擊意思，原則上難以主張正當防衛，但**若一方明顯屬於不法侵害之發動者**，他方仍得主張正當防衛。
2. **被害人承諾不及於重傷**：即使雙方同意互毆，也不能認為承諾範圍擴及重傷結果。
3. **正當防衛 vs 緊急避難**：面對「不法侵害」優先適用正當防衛；緊急避難適用於「合法之危難」。

三、正當防衛的反擊行為（108年第27題）

乙以重傷故意，拿木棒朝甲的頭部猛力攻擊，甲立刻閃身並出手將木棒撥開，致甲手指骨折，而撥開的木棒反彈打中乙的頭部，造成乙受傷。甲、乙兩人可能會負何種刑事責任？

(A) 甲為無罪，乙成立重傷未遂罪
(B) 甲成立過失傷害罪，乙成立重傷未遂罪
(C) 甲為無罪，乙亦無罪
(D) 甲成立過失傷害罪，乙成立傷害既遂罪

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確（本題答案）	**甲**：面對乙的不法侵害（重傷故意攻擊），甲閃身撥開木棒屬**正當防衛**(§23)，木棒反彈打中乙為防衛行為的附隨結果，未逾越必要程度，阻卻違法→無罪。**乙**：以重傷故意攻擊甲（木棒朝頭部猛力攻擊），已著手實行但未造成重傷結果（甲僅手指骨折為閃避所致，非乙的攻擊直接造成），成立**重傷未遂罪**(§278 III)。
(B)	✗ 錯誤	甲的行為屬正當防衛，**不成立過失傷害罪**。
(C)	✗ 錯誤	乙已著手實行重傷行為，**不可能無罪**。
(D)	✗ 錯誤	甲正當防衛不成立犯罪；乙是重傷故意而非傷害故意，且未造成重傷結果→**重傷未遂**而非傷害既遂。

[!NOTE]
重點整理

1. **正當防衛之附隨結果**：正當防衛行為所產生的附隨結果（如木棒反彈傷及攻擊者），屬於防衛行為之自然延伸，未逾越必要程度者，仍在正當防衛之範圍內。
2. **重傷未遂之認定**：以重傷故意著手實行，但未造成重傷結果者，成立重傷未遂罪(§278 III)。
3. **防衛行為之必要性判斷**：面對持木棒朝頭部猛力攻擊之重傷故意侵害，閃身撥開木棒之反擊行為屬必要且相當之防衛手段。

四、正當防衛與緊急避難之區分（108年第7題）

甲路過鄰居家門時，鄰居所飼養的秋田犬突然發狂跑出來攻擊甲，甲乃持木棍自衛反擊，但秋田犬仍然不放棄、繼續攻擊，甲在不得已的情況下只能以木棍將鄰居的秋田犬擊斃。甲為自衛而持木棍將秋田犬擊斃之行為，下列敘述何者正確？

(A) 正當防衛
(B) 防衛過當
(C) 緊急避難
(D) 避難過當

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	正當防衛(§23)的對象必須是「**人**」的不法侵害。動物攻擊非「人的不法侵害」，不能成立正當防衛。通說認為動物僅為**自然力的一部分**。
(B)	✗ 錯誤	既然不成立正當防衛，也就**沒有防衛過當的問題**。
(C)	☑ 正確（本題答案）	動物攻擊屬於「**緊急危難**」(§24)。甲為避免自己的生命身體遭受危害，在不得已的情況下擊斃攻擊犬，符合緊急避難的要件（現在危難、非自招、不得已、出於避難意思）。
(D)	✗ 錯誤	甲在不得已的情況下才擊斃繼續攻擊的犬隻，手段**未逾越必要程度**，不構成避難過當。

[!NOTE]
重點整理

1. **動物攻擊非不法侵害**：正當防衛(§23)之「不法侵害」限於「人」之行為，動物攻擊僅屬自然力，應適用緊急避難(§24)。
2. **正當防衛 vs 緊急避難之關鍵區分**：面對「人的不法侵害」→正當防衛；面對「自然力或合法行為之危難」→緊急避難。
3. **避難行為之比例原則**：避難行為須在「不得已」之情況下為之，且手段未逾越必要程度，始不構成避難過當。

貳、依法令行為（刑法§21）

一、阻卻違法事由綜合（110年第8題）

關於乙之行為，下列何者得以阻卻違法而不罰？

(A) 小學生甲服儀不整，班導師乙處罰甲青蛙跳操場10圈，致甲橫紋肌溶解送醫治療
(B) 上級公務員甲為了調查配偶有無外遇，於是命令下級公務員乙利用職務之便竊聽其配偶的手機對話，乙據以執行該命令
(C) 檢察官甲開具拘票，司法警察乙持之拘提被告丙到案。乙事後始發現，甲所發之拘提命令不符合刑事訴訟法第76條所定之各款事由
(D) 甲偷拿其父乙的錢去花用，乙知悉後大發雷霆，憤怒之餘持籐條將甲打得遍體鱗傷

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	教師對學生有管教權，但**懲戒手段須合理且不得危害學生身心健康**。青蛙跳10圈致橫紋肌溶解已逾越合理管教範圍，不得主張正當行為阻卻違法。
(B)	✗ 錯誤	依刑法§21第2項，公務員依上級命令行為不罰，但**命令內容明顯違法者除外**。甲命令乙竊聽配偶電話係「為私人目的利用公權力」，屬於**明顯違法命令**，乙不得主張依上級命令之行為阻卻違法。
(C)	☑ 正確（本題答案）	司法警察乙持檢察官開具之拘票執行拘提，雖事後發現不符合法定事由，但乙在**執行時有正當理由信賴該命令之合法性**（拘票為具有管轄權之檢察官所核發），非明顯違法，得依§21第2項主張依法令行為阻卻違法。
(D)	✗ 錯誤	父母對子女有懲戒權，但**打得遍體鱗傷已逾越合理管教範圍**，構成傷害罪，不得主張正當懲戒權阻卻違法。

[!NOTE]
重點整理

1. **依上級命令之行為（§21 II）**：公務員依上級命令行為得阻卻違法，但以命令**非明顯違法**為前提。下級公務員對上級命令有「形式審查義務」，若命令內容明顯違法（如為私人目的），則不得主張阻卻違法。
2. **合理管教範圍**：教師懲戒權與父母管教權均有界限，不得造成學生/子女身體健康之重大危害。
3. **拘票執行之信賴**：基層執法人員對合法機關依法核發之令狀，通常無實質審查義務，得信賴上級命令之合法性。

二、依上級命令行為（113年第8題）

某行政機關科長甲，因涉嫌偽造文書，經檢察官偵查。對此，甲供稱，當時直屬長官乙命令自己實行該行為，甲雖明知自己偽造文書，但無奈乙宣稱會負責一切責任，甲不得已只好照辦。經查，甲所述屬實，下列敘述何者正確？

(A) 甲得主張依所屬上級公務員命令之行為，阻卻違法
(B) 甲得主張無期待可能性，阻卻責任
(C) 乙是偽造文書罪的間接正犯
(D) 乙是偽造文書罪的教唆犯

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	甲**明知偽造文書為違法行為**，上級命令內容為「偽造文書」，屬於**明顯違法之命令**，甲不得依§21第2項主張依上級命令阻卻違法。
(B)	✗ 錯誤	甲雖無奈但仍有選擇拒絕之可能，尚未達到**無期待可能性**之程度。甲並非處於生命、身體受到急迫威脅之情境，僅是上級長官口頭命令，一般仍可期待甲拒絕該違法命令。
(C)	✗ 錯誤	間接正犯係以他人為「工具」而犯罪，但甲**明知行為違法且有自由意志**，並非被乙利用之工具，乙不構成間接正犯。
(D)	☑ 正確（本題答案）	乙命令甲偽造文書，使甲「萌生犯意」而實行犯罪，符合**教唆犯**之定義（§29：教唆他人使之實行犯罪行為者）。甲為正犯，乙為教唆犯。

[!NOTE]
重點整理

1. **明顯違法命令不阻卻違法**：命令下級偽造文書，內容明顯違法（偽造文書為刑法明文處罰之犯罪），下級不得以「依上級命令」免責。
2. **間接正犯 vs 教唆犯**：關鍵在於被利用者是否具有「完全之行為支配力」。甲明知違法仍自主決定執行，具有正犯性，乙非間接正犯而是教唆犯。
3. **無期待可能性**：僅在行為人處於極端壓力（如生命威脅）下，無法期待其為合法行為時，始得阻卻責任。單純服從上級命令通常不構成。

三、偵查行為與阻卻違法（111年第35題）

甲為已婚之人，因有犯罪嫌疑，受到偵查機關的調查。警察乙將ＧＰＳ追蹤器裝設在甲車的底盤，竊錄、掌握其行蹤。警察丙則竊取甲之信件，以蒸氣開拆信件，但因信函以外文撰寫，丙無法理解其內容，遂重新彌封放回甲之信箱。復因甲經常鬼鬼祟祟講電話，其配偶丁懷疑甲有外遇，因而竊錄甲之電話。依近來的實務見解，下列敘述何者正確？

(A) 乙裝設ＧＰＳ追蹤器竊錄甲行蹤之行為雖係國家偵查犯罪行為，但不得主張依法令之行為阻卻違法，應成立刑法第315條之1窺視竊聽竊錄罪
(B) 丙雖開拆甲之信函，但因無法了解其內容，因而僅成立刑法第315條妨害書信秘密罪之未遂
(C) 丙開拆甲之信函的行為，成立刑法第133條郵電人員妨害郵電秘密罪
(D) 丁雖竊錄甲之電話的行為，但因配偶互負保障婚姻純潔之義務，應認為丁之行為有法律上之正當理由，因而不成立刑法第315條之1窺視竊聽竊錄罪

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確（本題答案）	依近來實務見解，**未經法院核發監視票（通訊監察書）**而以GPS追蹤器竊錄行蹤，即使係為偵查犯罪目的，仍屬**無正當理由之竊錄行為**，不得主張依法令行為阻卻違法。國家偵查權的行使亦須遵守法律保留原則與令狀原則。
(B)	✗ 錯誤	妨害書信秘密罪（§315）為「開拆或隱匿他人之封緘信函」，**開拆行為完成即既遂**，不以理解內容為必要。丙已完成開拆，應成立既遂犯。
(C)	✗ 錯誤	§133郵電人員妨害郵電秘密罪之主體限於「郵電機關人員」，丙為警察，**非郵電機關人員**，不符合本罪主體要件。
(D)	✗ 錯誤	依近來實務見解，**配偶關係不構成竊錄之正當理由**。即使配偶互負忠貞義務，仍不得以此為由侵害他方之隱私權。丁竊錄甲之電話仍成立§315之1。

[!NOTE]
重點整理

1. **偵查行為非當然阻卻違法**：國家偵查犯罪行為仍須依法為之，未經合法授權（如通訊監察書）之強制偵查手段，不得主張依法令行為阻卻違法。
2. **配偶權非竊錄正當理由**：近來實務變更見解，認為配偶間互負忠貞義務，不構成竊錄他方通訊之正當理由。隱私權之保障不因婚姻關係而消滅。
3. 此題同時涉及**妨害秘密罪**之構成要件討論。

參、義務衝突（114年第4題）

甲在偏遠山區開雙人座跑車載母親乙兜風回程下山途中，因打滑失控而撞上由丙所騎機車，致乙、丙受傷，但因甲見丙只有手臂擦傷而乙傷勢嚴重有生命危險，故不顧丙的傷勢而將乙載往山下某醫院進行救治。有關甲之行為，下列敘述何者錯誤？

(A) 不得主張正當防衛
(B) 得主張義務衝突
(C) 欠缺刑法第185條之4發生交通事故逃逸罪之逃逸故意
(D) 甲之行為該當刑法第185條之4發生交通事故逃逸罪之逃逸行為

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	交通事故係因打滑失控所致，並非他人之「不法侵害」，**不符合正當防衛之「現在不法侵害」要件**，故不得主張正當防衛。
(B)	☑ 正確	甲同時面臨救助母親乙（生命危險）與留在現場照顧丙（手臂擦傷）之**兩個互相衝突之義務**，在僅有雙人座跑車之情形下無法同時履行，甲選擇履行較高位階之義務（救助生命危險之乙），**得主張義務衝突阻卻違法**。
(C)	✗ 錯誤（本題答	甲**明知發生交通事故且丙受傷**，卻選擇離開現場，主觀上對「逃逸」有認識且有意為之，**具有逃逸故意**。甲離開現場係出於救助乙之目的，但不影響逃逸故意之認定，此屬阻卻違法層次之問題（義務衝突），而非故意層次。

案）

(D) ☑ 正確　甲駕車離開事故現場，客觀上已**該當逃逸行為**。逃逸係指離開事故現場而逸走，甲確實已離開。

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> 1. **義務衝突**：行為人同時面臨數個作為義務，無法同時全部履行時，若選擇履行較高位階之義務（如生命法益 > 輕傷），得阻卻違法。
> 2. **故意 vs 阻卻違法之區分**：甲明知離開現場卻仍為之，具有逃逸故意（構成要件該當）；但因義務衝突而得於違法性層次阻卻。二者不應混淆。
> 3. **正當防衛不適用於非人為不法侵害**：交通事故如係因自然力（打滑）或行為人自身過失所致，不構成「現在不法侵害」。

肆、被害人承諾（超法規阻卻違法事由）

一、被害人承諾要件（113年第7題）

關於「得被害人之承諾」作為超法規阻卻違法事由，下列敘述何者正確？

(A) 被害人之承諾能力，不以民法上之行為能力為標準，而是依個案之認識與判斷能力而定
(B) 被害人因受行為人詐欺而為承諾者，承諾之效力未定，被害人得事後選擇撤銷或不撤銷其承諾
(C) 被害人得承諾放棄的法益，除個人法益之外，尚可包含社會法益
(D) 基於個人自主權之尊重，得被害人承諾之範圍可包括生命法益

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確（本題答案）	被害人承諾之「承諾能力」，係指**對法益處分之意義與後果具有認識與判斷能力**，不以民法上行為能力為準。此乃刑法獨立之判斷標準，未成年人在個案中若具備足夠認識能力，仍得為有效承諾。
(B)	✕ 錯誤	因詐欺而為之承諾，其效力並非類推適用民法之「效力未定」或「得撤銷」。刑法上，**因詐欺而為之承諾原則上無效**，蓋被害人之意思決定自由遭到侵害，非出於真正自由意志。
(C)	✕ 錯誤	被害人承諾僅能處分**個人法益**（如身體、自由、財產等），不得處分社會法益或國家法益，蓋此等法益非個人所得任意處分。
(D)	✕ 錯誤	我國刑法明定「加工自殺罪」（§275），可見**生命法益不得由被害人承諾處分**。即使被害人承諾放棄生命，行為人仍成立犯罪（§275），僅為減輕處罰。

> [!NOTE]
> **重點整理**
> 被害人承諾之有效要件：
>
> 1. **承諾能力**：依個案認識與判斷能力而定，非以民法行為能力為準
> 2. **承諾範圍**：僅限可處分之個人法益，不包括生命法益與社會法益
> 3. **承諾之自由性**：須出於被害人自由意志，因詐欺或脅迫而為之承諾無效
> 4. **承諾時點**：須在 **行為前** 或 **行為時** 為之
> 5. **承諾之明示或默示**：得以明示或可推知之方式為之

> **重點整理2**
>
> 1. 對象：僅限個人法益（且不含生命、重大重傷）。
> 2. 時機：必須在**「行為前」** 或**「行為時」**。事後原諒（事後承諾）頂多影響刑度，不能阻卻違法。
> 3. 能力：自然意思能力（知道痛、知道東西會不見）。
> 4. 手段：不能違反善良風俗（例如：承諾讓對方打斷一條腿來領保險金，這種承諾因違反倫理而無效）。

二、被害人承諾能力與推測承諾（114年第2題）

甲為 17 歲之高中生，為博取心怡對象的好感，而願意接受紋身師傅乙於其手臂刺一個十元硬幣大小的愛心圖案。下列敘述何者正確？

(A) 甲不具民法上之行為能力，故其承諾無效
(B) 未成年人對自己的身體並無處分權，須由其父母代為承諾始可
(C) 乙不得主張推測承諾以阻卻傷害罪之違法性
(D) 手臂刺青難以回復原樣，屬刑法第10條之重傷

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	如前述，被害人承諾之承諾能力**不以民法行為能力為準**。17歲高中生對於手臂刺小圖案之意義與後果，通常具備足夠認識與判斷能力，其承諾應屬有效。
(B)	✗ 錯誤	被害人承諾涉及**法益持有人對自身法益之處分**，未成年人若具承諾能力即得自行為之，**無須由法定代理人代為承諾**。身體法益之處分不適用民法之法定代理制度。
(C)	☑ 正確（本題答案）	本案中甲已**明確表示承諾**接受紋身，既有實際承諾存在，即無援引「推測承諾」之必要。**推測承諾係在無法取得被害人實際承諾時，推測其若知情將會同意之情形**，本案不符。
(D)	✗ 錯誤	手臂刺一個十元硬幣大小之愛心圖案，僅係皮膚表層之傷害，**不構成§10第4項所定之重傷**（毀敗或嚴重減損身體機能等）。

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> 1. **承諾能力之獨立性**：刑法上之承諾能力不從屬於民法行為能力，個案判斷即可。
> 2. **推測承諾 vs 實際承諾**：推測承諾為實際承諾之補充，僅在無法取得被害人實際承諾時（如被害人昏迷、不在場）始有適用。已有實際承諾時，無須援引推測承諾。
> 3. **承諾範圍**：被害人得承諾之範圍以普通傷害為限，不及於重傷害。

三、因脅迫而為之承諾（114年第22題）

甲、乙均已成年，甲某日潛入乙家中，見乙正在熟睡中，色心大起，遂起意觸摸乙之胸部、生殖器，乙因有異狀而醒來，甲見狀擔心乙聲張此事，遂另以其係神明轉世，告知乙若不與其發生性行為，將遭天譴。乙聞言大驚，心裡便害怕起來，遂同意與甲發生性行為。甲於性行為過程中，在乙不知情之下，手持智慧型手機開啟拍攝功能拍攝與乙間之性交過程。依實務見解，下列敘述何者錯誤？

(A) 甲在乙熟睡階段觸摸乙身體及生殖器之行為，構成乘機猥褻罪
(B) 甲以遭天譴之事告以乙而使乙同意與其性交，雖然是怪力亂神之事，但乙之同意仍為有效
(C) 甲成立刑法第222條加重強制性交罪
(D) 甲若構成加重強制性交罪，則毋庸另論刑法第315條之1第2款之無故竊錄他人身體隱私部位罪

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	乙在熟睡中，處於**不知抗拒**之狀態，甲趁機觸摸乙之胸部、生殖器，構成§225第2項之**乘機猥褻罪**。
(B)	✗ 錯誤（本題答案）	甲以「不與其性交將遭天譴」恐嚇乙，使乙因恐懼而同意性交。此種以**恐嚇手段（含怪力亂神之恐嚇）**使被害人屈從之「同意」，並非出於被害人之**真正自由意志**，應認為**違反被害人意願**，非有效之承諾。依實務見解，此屬§221所稱「其他違反其意願之方法」。
(C)	☑ 正確	甲侵入乙之住宅犯強制性交罪，符合§222第1項第7款「侵入住宅犯之」之加重要件，成立**加重強制性交罪**。
(D)	☑ 正確	甲若成立加重強制性交罪，其竊錄性交過程之行為，依實務見解，屬於加重強制性交罪之**伴隨行為**，不另論竊錄罪。

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> 1. **恐嚇所生之承諾無效**：被害人因恐嚇、脅迫而為之「同意」，非出於自由意志，不構成有效之被害人承諾。
> 2. **怪力亂神亦屬恐嚇**：以超自然力量脅迫（如天譴、詛咒等），使被害人心生畏懼而屈從，仍屬「違反意願之方法」。
> 3. 此題同時涉及**乘機猥褻罪**與**加重強制性交罪**之要件。

伍、誤想防衛（110年第7題）

> ⚠ 本題亦收錄於「故意與錯誤論」主題，此處側重阻卻違法事由之面向。

甲在登山時，看見乙正在持小刀割丙的小腿，誤以為乙在傷害丙，故立即持登山杖擊傷乙。實際上，乙正在為遭毒蛇咬傷的丙緊急治療傷口。依實務見解，下列有關甲刑責之敘述何者正確？

(A) 甲之行為係誤想防衛，屬於包攝錯誤，得依刑法第16條減輕刑責
(B) 甲之行為係誤想防衛，不成立故意傷害罪，仍可能成立過失傷害罪
(C) 甲之行為係誤想避難，不成立故意傷害罪，仍可能成立過失傷害罪
(D) 甲之行為係誤想避難，仍可阻卻違法，不成立犯罪

答案：(B)

選

項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	誤想防衛屬於**容許構成要件錯誤**（誤認阻卻違法事由之前提事實），非屬包攝錯誤（對法律規範適用範圍之誤認），不適用§16禁止錯誤之規定。
(B)	☑ 正確（本題答案）	甲**誤以為乙在傷害丙**（誤認存在現在不法侵害），基於防衛意思而攻擊乙，此為**誤想防衛**。依實務見解（採類推構成要件錯誤說），誤想防衛**阻卻故意**，不成立故意犯；但如有過失（甲未盡注意義務確認實際情況），仍可能成立過失犯。
(C)	✗ 錯誤	甲認為乙在傷害丙，是**誤認存在「不法侵害」**，屬於誤想「防衛」，而非誤想「避難」。緊急避難之前提是「合法之危難」，非不法侵害。
(D)	✗ 錯誤	誤想防衛（或誤想避難）**不能真正阻卻違法**，蓋客觀上並無阻卻違法事由之前提事實存在。其法律效果係在罪責或故意層次處理，而非違法性層次。

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> 1. **誤想防衛**：行為人誤認存在正當防衛之前提事實（現在不法侵害），屬「容許構成要件錯誤」。
> 2. **法律效果**：實務採「類推適用構成要件錯誤」之見解，阻卻故意，但仍得成立過失犯。
> 3. **與包攝錯誤區分**：誤想防衛是「事實認知錯誤」（誤認事實），包攝錯誤是「法律適用錯誤」（誤認法律），二者法律效果不同。

體系歸納

一、阻卻違法事由出題統計

年度	題號	子主題	核心考點
108	§7	緊急避難	動物攻擊非不法侵害、正當防衛與緊急避難之區分
108	§27	正當防衛	正當防衛之反擊行為、防衛附隨結果、重傷未遂
110	§7	誤想防衛	容許構成要件錯誤之定性與法律效果
110	§8	依法令行為	依上級命令行為之界限、教師管教權、父母懲戒權
111	§5	正當防衛	互毆不成立聚眾鬥毆、防衛與避難之區分、承諾不及於重傷
111	§35	依法令行為	偵查行為非當然阻卻違法、配偶權非竊錄正當理由
112	§6	正當防衛	業務特別義務者之防衛、利益衡量不要求、無責任能力人、防衛意思
113	§7	被害人承諾	承諾能力、詐欺承諾無效、法益範圍、生命法益不可處分
113	§8	依上級命令	明顯違法命令不阻卻違法、間接正犯與教唆犯之區分
114	§2	被害人承諾	承諾能力獨立於民法、推測承諾之補充性
114	§4	義務衝突	義務衝突阻卻違法、正當防衛不適用於非不法侵害、逃逸故意
114	§22	被害人承諾	因恐嚇而為之承諾無效、怪力亂神亦屬違反意願

二、阻卻違法事由體系表

類型	法律依據	核心要件	常考重點
正當防衛	§23	現在不法侵害＋防衛必要性＋防衛意思	不要求利益衡量；業務特別義務者僅限縮手段不排除權利；對無責任能力人仍可防衛；互毆原則上不成立正當防衛
緊急避難	§24	緊急危難＋避難行為＋利益衡量（不得逾越必要程度）	與正當防衛區分：避難對象為合法利益，需利益衡量；動物攻擊屬緊急危難而非不法侵害
依法令行為	§21 I	依法律或法律授權之命令所為之行為	偵查行為須有法律授權；教師管教權與父母懲戒權有界限
依上級命令	§21 II	公務員依上級命令行為＋命令非明顯違法	明顯違法命令不阻卻違法；下級有形式審查義務
被害人承諾	超法規	承諾能力＋個人法益＋自由意志＋行為前或行為時	承諾能力獨立於民法行為能力；不及於生命法益；詐欺/脅迫之承諾無效；不及於重傷
推測承諾	超法規	無法取得實際承諾＋可推測被害人會同意	為實際承諾之補充；已有實際承諾時不適用
義務衝突	超法規	數義務同時存在＋無法全部履行＋選擇較高位階義務	生命法益 > 身體法益 > 財產法益
誤想防衛	容許構成要件錯誤	誤認存在阻卻違法之前提事實	阻卻故意，得成立過失犯；非包攝錯誤，不適用§16

三、出題趨勢分析

- **被害人承諾**為近年高頻考點（113、114連續出題），尤其重視承諾能力、承諾有效性、法益範圍等要件。

- **依法令行為/依上級命令**穩定出題，重點在於「明顯違法命令」之判斷及偵查行為之合法性界限。
- **正當防衛**出題著重於「不需利益衡量」、「互毆與防衛之區分」、「防衛反擊之附隨結果」等進階概念。108年即考出正當防衛與緊急避難之區分（動物攻擊）。
- **義務衝突**於114年首次出現，為超法規阻卻違法事由之新考點。
- **誤想防衛**跨越阻卻違法事由與錯誤論兩大主題，需同時掌握。

資料來源： 108–114 年司律一試刑法考古題
最後更新： 2026-06-19